

1500716-08.2020.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... consigo e guardado, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência química e física, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, bem como porque teriam associado-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Os réus foram citados e apresentaram defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida.

Durante a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

1500716-08.2020.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500716-08.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO DE FREITAS GAMA e outro

Vistos.

RODOLFO DE FREITAS GAMA e ELIANE JARDIM MOREIRA foram denunciados como incursos nas penas dos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, porque, em 20/11/2020, na Rua Aurélio Menuzo, 397, nesta cidade, teriam trazido consigo e guardado, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência química e física, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, bem como porque teriam associado-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Os réus foram citados e apresentaram defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida.

Durante a audiência de instrução foi produzida prova oral, tendo sido os réus interrogados.

As partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público requerido a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia, posto entender comprovadas a materialidade delitiva e a autoria; a defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réus pela insuficiência probatória, e, de forma subsidiária, pela concessão dos benefícios legais.

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados. D E C I D O:

No mérito, a ação penal merece prosperar em parte.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 15/16, em que se descreve o material apreendido. Por outro lado, o exame químico-toxicológico revelou consistir a substância apreendida em entorpecente, concluindo, pois, por sua toxicidade e potencialidade para causar dependência (fls. 361/366). Assim, a materialidade delitiva foi comprovada.

Análise a autoria delitiva.

Com efeito, o policial APARECIDO VASCONCELOS disse em juízo que na data dos fatos recebeu a notícia de que o réu estava praticando tráfico de drogas no bairro Residencial Bordon, em Sumaré. Foi até o endereço indicado, e o avistou em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu dispensou a embalagem ao solo e tentou adentrar à residência, mas foi perseguido pela testemunha e foi abordado no corredor da residência. Ao ser abordado, o réu confessou que as drogas lhe pertenciam e iria abastecer o bairro Picerno, repassando a droga para menores. Ele disse que a droga era passada a ele por uma pessoa conhecida como "Neguinho". A residência pertencia à cunhada do réu, a ré Eliane, onde foi localizada o restante da droga apreendida, em um dos cômodos, no interior de um guarda-roupas. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia, após serem presos em flagrante. Eliane estava com uma porção de cocaína na mão. Rodolfo disse que ela não sabia das drogas. A droga estava na parte térrea da casa da acusada. O cômodo somente tinha um guarda-roupa. Rodolfo disse que a droga do armário não era dele. A ré estava na parte da garagem do imóvel quando da abordagem.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial ROMÁRIO AUGUSTO REBOLO GOMES, acrescentando que com o réu foi encontrada uma sacola com cerca de 60 pinos de cocaína. Eliane disse que iria tomar satisfações com o acusado sobre a droga. A droga apreendida com o acusado e com a acusada estavam embalados da mesma forma. Rodolfo assumiu a droga apreendida, tendo Eliane negado a propriedade da droga. A droga estava em um cômodo onde havia uma guarda roupa com roupa de mulher. A droga estava escondida no guarda-roupa. No imóvel morava a acusada Eliane. De acordo com eles, o acusado não morava no local, mas a acusada disse que o acusado frequentava a casa porque era mulher da irmã da acusada.

Neste passo, como já declarou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus depoimentos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem em defesa coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286), e, ainda, "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente "(RT 614/275). Além disso, inexistente qualquer razão comprovada e justificada para retirar a credibilidade destes depoimentos policiais, os quais se mantêm válidos e aptos a sustentarem decreto condenatório.

JANIFER RAQUELI APOLINÁRIO disse em juízo que é amiga da ré ELIANE há muitos anos e sabe que a Eliane estava reatando o relacionamento com seu ex-marido, e ela falou que seu ex-cunhado estava se hospedando em sua residência sem ela saber. A ré Eliane afirmou que as drogas apreendidas em sua casa não lhe pertenciam, e que estava em processo de reabilitação para se curar do vício contra as drogas. Não presenciou os fatos, nem a abordagem da polícia. Eliane usava drogas e tem mais de

um ano que ela esta tentando parar o vicio. Não sabe dizer quando ela voltou para a casa, mas acha que foi em dezembro. A casa era alugada e ela deixou a casa fechada, mas continuou pagando aluguel. Acha que ela chegou na casa dela quatro dias antes da prisão. Viu o acusado perto da casa da corré, mas não sabia que ele estava morando lá. Não sabe se a acusada estava na casa ou na casa da irmã dela.

O réu RODOLFO DE FREITAS GAMA confessou em juízo a pratica delitativa. Disse que na época dos fatos estava trabalhando, mas ganhava um salário mínimo. E como o dinheiro não estava sendo suficiente para sustentar seus dois filhos, acabou aceitando a oferta de uma pessoa conhecida como "neguinho", para guardar drogas no imóvel da ré Eliane. Afirmou que pegou as chaves da residência da cunhada, a ré Eliane, escondido da sua esposa, e que nenhuma das duas sabia que as drogas estavam na casa. Disse que tinha coisas pessoais de Eliane na casa e disse que ela discutiu com ele quando a policia chegou. Quando a policia chegou ela estava discutindo com ele por ele ter pego as chaves da casa sem autorização.

A ré ELIANE JARDIM MOREIRA, por sua vez, negou a autoria do crime. Relatou que na ocasião estava na cidade de Barretos, tentando reatar a relação com seu marido. Recebeu um telefonema relatando que havia barulho em sua residência, retornou para a sua casa, e chamou os policiais para relatar o barulho. Ao chegar na residência, avistou o réu Rodolfo na área da casa, e um pino de droga ao solo. A ré discutiu com Rodolfo e este confessou que havia se apoderado das chaves com a sua irmã, sem que ela soubesse, e permanecido na casa durante cerca de três meses, período que a vítima estava na cidade de Barretos. Trabalhava como faxineira. Ninguém morava na casa quando dos fatos. Usa esporadicamente drogas. Já foi condenada por tráfico de drogas e nada tem contra os policiais. A casa era alugada. Deixou a casa para ir para Barretos, mas continuou a pagar aluguel da casa de Sumaré. Negou que estivesse tomando cerveja com Rodolfo quando da abordagem. Disse isso na policia porque estava com pressão alta. Sua filha estava em Barretos quando dos fatos. Disse que sua irmã ligou e disse que Rodolfo tinha pego as chaves do local. E por isso voltou de Barretos. Sua filha ajudou na construção da nova casa.

Este contexto probatório, pela prevalência dos imparciais depoimentos policiais em relação à isolada afirmação dos acusados, autoriza o reconhecimento de que a droga apreendida estava na posse dos acusados, porquanto foi apreendida no interior da casa da acusada, tendo sido admitido pelo corréu ser ele a pessoa responsável pela guarda da droga no local.

Considerando-se a confissão judicial do acusado e o relato dos policiais, dando conta de que foi este acusado quem indicou o local em que a droga estava guardada, é de se reconhecer a responsabilidade penal deste acusado pela ilícita guarda do material entorpecente.

No tocante à acusada, é de se reconhecer que a droga foi apreendida no interior da casa a qual alugava, o que, de plano indica a presunção de sua responsabilidade pela posse do material ilícito, mormente porque o corréu não residia no local junto com a acusada, que, inclusive, já foi condenada pela mesma prática de tráfico de drogas (fls. 60/61). É certo que esta presunção pode ser infirmada, mas para tanto é necessária a produção de prova robusta e convincente, o que não ocorreu no caso dos autos.

De fato, a acusada apresentou duas versões diferentes quando comparado suas declarações na fase policial e em juízo. Na primeira disse que estava com seu cunhado tomando um cerveja quando foi abordada pela policia, dizendo que estava na posse de uma porção de maconha, enquanto em juízo disse que não estava morando na sua casa em Sumaré e que chamou a policia relatando que tinha recebido um telefonema dizendo que havia um barulho em sua casa. Disse que ao chegar na sua casa viu Rodolfo em seu interior e começou a discutir com ele, dizendo que ele ficou três meses em sua casa sem seu conhecimento.

Além da versão contraditória, que infirma a veracidade das declarações da acusada, o depoimento da testemunha ouvida nos autos arrolada pela defesa, dando a entender que a acusada não sabia do paradeiro do ex-cunhado, deve ser recebido com reservas, não sendo suficiente para infirmar a mencionada presunção de responsabilidade, dado que é a testemunha amiga da acusada.

Não se olvide, ainda, que a alegação de que o acusado obteve as chaves clandestinamente do imóvel da acusada sem seu conhecimento e que ali guardou drogas é inverossímil, sendo fato por demais incomum, mormente porque o acusado é seu ex-cunhado..

Não provou a acusada, ainda, que tenha ligado para a polícia, como disse que o fez.

Ademais, a acusada não postulou, nem produziu a oitiva de testemunhas relevantes para corroborar sua inusitada versão dos fatos, tais como a oitiva do alegado companheiro para dizer que ela não morava mais no local e a oitiva da mulher do acusado para provar os fatos relacionados às chaves do local.

Enfim, a defesa não logrou provar o álibi da acusada como lhe competia, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, prevalece a responsabilidade penal da acusada pela posse de tão grande quantidade de droga em seu imóvel domiciliar, estando provado o dolo de sua conduta em concorrer com a guarda do material entorpecente.

Tendo em vista a elevada quantidade de droga e sua forma de acondicionamento, aproximadamente 192g de cocaína, 7 quilos de maconha, 314 porções de cocaína, pesando 518g, somado ao dinheiro trocado apreendido (cerca de dois mil reais), é forçoso reconhecer que a droga apreendida destinava-se ao tráfico e não ao consumo próprio, pois tais circunstâncias, à falta de outros elementos, são incompatíveis com o mero consumo próprio.

Vale consignar que: "Não se desconhece que os acusados possam ser usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício" (TJSP - Ap. nº 0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013).

Em que pese a configuração do crime de tráfico de drogas, o crime de associação para a prática do crime de tráfico não restou confirmado pela prova oral.

É cediço que o delito do art. 35 da Lei 11.343/06 reclama prova minuciosa da estabilidade da associação, como já reconheceu o C. Superior Tribunal de Justiça: "O delito de associação para o tráfico não se confunde com uma associação meramente eventual (simples co-autoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira *societas sceleris*." (STJ - HC 99373 / MS - Rel. Des. Jane Silva - DJe 14/04/2008).

No caso dos autos, esta estabilidade não se configurou.

De fato, os elementos probatórios angariados nos autos indicam que os réus praticaram o tráfico de drogas em concurso de agentes, como acima exposto. Todavia, não houve produção de prova que tenha comprovado a duração do mencionado concurso de agentes, sendo certo que, em verdade, sequer a denúncia descreve o período em que teria ocorrido a associação para o tráfico, limitando-se apenas a dizer que foi no dia dos fatos. Assim, é de se reconhecer a inexistência de prova suficiente para sobre a comprovação específica da estabilidade da associação do réu e do menor, impondo-se absolvê-los por insuficiência probatória em relação

ao crime do art. 35 da Lei de Drogas.

Caracterizado o crime de tráfico, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Réus: RODOLFO DE FREITAS GAMA e ELIANE JARDIM MOREIRA

Para cada um dos acusados, a pena-base do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas será fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a especial circunstância de se tratar parte da droga apreendida de cocaína, entorpecente este que causa dependência química, vulnerando com maior intensidade a saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila, impondo-se a exasperação da pena. Além disso, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (192g de cocaína, 7 quilos de maconha, 314 porções de cocaína, pesando 518g,), suficiente para a intoxicação de milhares de usuários de drogas também indica a especial reprovabilidade da conduta a justificar a elevação da pena. A jurisprudência corrobora este entendimento: " A natureza e a quantidade da droga apreendida, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, são circunstâncias que, por si só, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal" (STJ - HC n.º 165.387/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 8-2-2011, DJe 21-2-2011). Fixo, em razão destas circunstâncias, a pena-base em 10 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal.

Pela reincidência dos réus (fls. 57/59 e 60/61), que prevalece sobre a confissão do réu Rodolfo (art. 67 do Código Penal), elevo a pena de ambos para 12 anos de reclusão e 500 dias-multa, tornando-a definitiva para ambos os acusados.

Note-se a inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei de DROGAS, ante a expressiva quantidade de droga apreendida e à própria reincidência de ambos os acusados.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, tendo em vista a muito expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, somada à reincidência dos acusados, e, ainda, a circunstância do crime de tráfico de drogas ser por demais grave, sendo certo que atualmente é o crime que mais vêm gerando violência no país, impondo-se reconhecer a necessidade da fixação do regime de cumprimento de pena mais rigoroso. Consigne-se que: "embora a primariedade e o quantum da pena possam permitir, em tese, a escolha de regime mais brando, não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso quando justificado pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal" (STJ - HC nº 313.085/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 21.6.2016)

Em atendimento ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, consigna-se que o tempo de prisão provisória em nada altera a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de prova acerca dos requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios legais, que deverão ser buscados junto ao juiz das execuções criminais (art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para absolvidos da acusação do crime do art. 35 da Lei de Drogas pela insuficiência probatória, CONDENAR RODOLFO DE FREITAS GAMA e ELIANE JARDIM MOREIRA à pena cada um de 12 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo unitário, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o réu Rodolfo recorrer em liberdade porquanto responderam ao processo no cárcere, subsistindo, ainda, os requisitos ensejadores da prisão decorrente do flagrante a fim de garantir a ordem pública contra novos atentados à saúde pública. Já a acusada poderá recorrer em liberdade, porque assim respondeu ao feito.

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser acolhida, pois, além da quantidade de pena cominada, em se tratando de delito gerador de violência social e familiar, e pelo princípio da suficiência, incide o entendimento jurisprudencial pelo qual: “como se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, cuja conduta enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade, não concedo o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime.”(TJSP - Apelação nº 0021376-71.2012.8.26.0309 - Jundiaí - Rel. Des. Alex Zilevoski, j. 8.4.13).

Com o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Recomendem-se o acusado no local em que se encontra recolhido.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais.

Declaro a perda em favor da União dos bens apreendidos nos autos, pois vinculados ao tráfico de drogas.

P.R.I.

Sumare, 21 de março de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito